

1501141-02.2020.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. LOCALIDADE DOMINADA POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE (STJ, AgRg no HC 471155/RJ) - grifou-se.

No caso, apesar de as provas dos autos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista - SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501141-02.2020.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501141-02.2020.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

JOSÉ EDUARDO ALVES DOS SANTOS, JOSÉ MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO e ROGÉRIO RIBEIRO DE SANTANA foram processados como incurso nos arts. 157, § 2º, II, III e V, e § 2º-A, e 288, todos do CP, porque em 30/5/2020, por volta das 10h, na rodovia Edgard Máximo Zambotto (SP 354), altura do km 60, nesta cidade e comarca, em conjunto com indivíduos não identificados, teriam subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo contra Cariolando de Jesus Silva e Ezequiel Silva e Brito, um caminhão Mercedes Benz/AXOR 1933 LS e seu semirreboque, placas PBU 9073 e PBW 7219, pertencentes à empresa PUJANTE TRANSPORTES LTDA., que transportava 51 (cinquenta e um) contêineres de mercadorias diversas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, em conjunto com outros indivíduos não identificados, teriam subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, uma carteira com documentos, cartões bancários, um aparelho celular e a quantia de R\$ 90,00 (noventa reais),

pertencentes à vítima Ezequiel Silva de Brito.

A denúncia foi recebida por decisão proferida em 16/6/2020, à fl. 311.

José Eduardo Alves dos Santos apresentou resposta à acusação às fls. 414/418, pugnando pela improcedência da demanda. Rogério Ribeiro de Santana às fls. 459/464, suscitando inépcia da inicial e prescrição do crime de roubo, requerendo a exclusão do acréscimo decorrente do uso de arma de fogo. José Marcos dos Santos Nascimento à fl. 487, expondo que os fatos não ocorreram como narrados na inicial.

Foram realizadas audiências de instrução (fls. 707/709, 896/871, 1261/1262 e 1280/1281).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público (fls. 1285/1303) reiterou os termos da denúncia. José Eduardo Alves dos Santos e Rogério Ribeiro de Santana (fls. 1311/1317) suscitaram a nulidade do processo até a fase de resposta à acusação. No mérito, requereram a absolvição. José Marcos dos Santos Nascimento igualmente alegou sua inocência.

O processo foi cindido quanto a José Marcos dos Santos Nascimento em razão de diligência pendente requerida pela defesa dos corréus e deferida pelo juízo, a qual foi juntada às fls. 1386/1387.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Expedido ofício à Tecban, responsável pela marca "Banco 24 horas", a resposta foi juntada às fls. 1386/1387, dando conta da ausência de armazenamento das filmagens, pois apenas fornece os equipamentos, sem responsabilidade pela captação audiovisual do ambiente. Instada a se manifestar, a defesa declarou ciência aos argumentos, sem nada requerer (fl. 1404).

Sobre a expedição de ofício visando obter a localização GPS das viaturas, irrelevante ao deslinde do caso, na medida em que os acusados foram presos em flagrante delito, com o encontro dos pertences de uma das vítimas no interior do automóvel.

Passa-se ao julgamento do mérito.

O crime de roubo está tipificado no art. 157, do CP: "Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência"; de acordo com Nucci (Código Penal Comentado, 21ª ed., p. 830/831), o roubo "nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça. "É a reiteração da fórmula do furto a que se incorporam circunstâncias, de maneira tal que um roubo não pode existir sem que previamente seja furto" - grifou-se.

Segundo o STJ (AgRg no HC 561498): "Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo. Outrossim, o delito previsto no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal (roubo impróprio), consoma-se no momento em que, após o agente se tornar possuidor da coisa, a violência é empregada, consoante ocorreu na presente hipótese" - grifou-se.

Na hipótese, ouvidas em juízo, as duas vítimas descreveram a dinâmica dos delitos. Ezequiel Silva de Brito afirmou que um carro "fechou"; desceram cinco pessoas do carro; se identificaram como polícia civil; tinham distintivo; abordaram motorista (estava ao lado esquerdo do depoente); colocaram capuz e foi colocado em um veículo; estavam indo até o Recife; "coisa de um segundo"; não justificaram porque estavam parando o carro; não estavam com máscara ou touca; falou que tinha rastreador no veículo porque se abrisse a porta o caminhão seria bloqueado; levaram seu celular e carteira com R\$ 90,00; carteira tinha documento pessoal; não realizou procedimento de reconhecimento na delegacia; recuperou carteira e dinheiro, no mesmo dia; um deles estava armado e encostou revólver na cabeça, quando colocado dentro do carro; "só fui erguer a cabeça quando cheguei na comunidade"; depois que foram abandonados, conseguiram ajuda em um restaurante e foram até a delegacia para

registrar ocorrência; delegacia não realizou o registro porque deveria ser feito no local do fato; o motorista do caminhão ligou para a empresa e cunhado, e foram até a delegacia de Campo Limpo Paulista; "simplesmente ele fechou a carreta [...] entrou na nossa frente [...] e falou: perdeu, entrega o caminhão; "falei: beleza, o caminhão tá entregue"; somente viu a arma quando apontaram na cabeça, no carro; já estava de capuz; apenas sentiu a arma, não viu; ficou mais ou menos uma hora na comunidade, junto com o motorista; veículo que foi colocado tinha quatro portas; dos cinco, três ficaram na carreta e dois levaram até o local (Zona Sul de São Paulo).

Cariolando de Jesus Silva relatou que estava saindo de Campo Limpo Paulista sentido Cajamar; carro "enquadrrou" e mandou descer; caminhão com carga dos Correios; um deles com arma em punho; foram levados para o Capão Redondo; foi liberado no dia seguinte; foram enquadrados no período da manhã; estavam com boné e máscara; não se recorda o veículo que eles estavam, nem a cor; não chegou a ver o rosto; não chegou a visualizar a subtração da carteira; não viu quem dirigiu o caminhão; pela voz só tinham duas pessoas no veículo [que foi usado para levá-los]; veículo com quatro portas.

Nesse sentido, roubos estão materializados pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 2/15), auto de exibição e apreensão (fls. 30/32), auto de entrega (fls. 33/34), relatório final (fls. 296/298), laudo pericial dos veículos (fls. 429/433), e depoimentos produzidos em sede policial e judicial. Além dos relatos das vítimas acima transcritos, foram ouvidos quatro policiais que participaram da ocorrência e realizaram as prisões em flagrante, a reforçar a materialização dos delitos.

Germano Faria Júnior relatou que estava trabalhando em Jarinu, quando COPOM informou possível roubo de carreta dos Correios próximo ao km 66, envolvendo veículo celta preto; dirigiu ao local e encontrou carreta no acostamento, com três pessoas na frente da cabine e um celta preto parado do lado oposto da rodovia, sentido Campo Limpo Paulista; quando avistaram a viatura, dois dos três atravessaram a rodovia e entraram no celta preto e um deles entrou na cabine do caminhão; abordaram celta preto mais a frente, com duas pessoas; nele estavam José Eduardo e Rogério; dentro do veículo havia mochila com várias ferramentas, uma habilitação – que não pertencia a nenhum dos dois – e uma CNH; indagados, confessaram participação de roubo à carreta; informaram guarnição de que carreta tinha seguido também sentido Campo Limpo Paulista, a qual foi posteriormente abordada por outra equipe; condutor da carreta também confessou roubo; posteriormente descobriram que CNH encontrada no celta era de uma das vítimas; depoente quem realizou a revista pessoal; aparelho celular apreendido: mais tarde foi informado que também pertencia a uma das vítimas, mas não tem certeza; rodovia da ocorrência: pista única sem divisão no meio; critério de abordagem: como o celta é mais veloz, resolveram abordá-lo primeiro. A carreta, por ser mais lenta, deixaram para depois; celta foi abordado menos de 1 km depois; a carreta foi abordada por volta do km 62.

Anselmo Wellington Bueno narrou que viatura recebeu informação do COPOM de que sedan branco e um veículo hatch estavam tentando "fechar" um caminho dos Correios na rodovia Edgard Máximo Zambotto; em dado momento visualizaram caminhão dos Correios estacionado no acostamento, sentido Jarinu, e um veículo hatch (celta preto) do outro lado do acostamento, sentido Campo Limpo Paulista; havia três pessoas ao lado do caminhão conversando; ao visualizarem a viatura, dois deles atravessaram a rodovia e entraram no celta e um deles entrou no caminhão; acompanharam o celta e abordaram; visualizaram caminhão fazer retorno e passar pela guarnição – que estava fazendo a abordagem – sentido Campo Limpo Paulista; não encontraram nada de ilícito no celta, nem com os acusados (José Eduardo e Rogério); encontraram celular e CNH em nome de Ezequiel Silva de Brito no porta-luvas [vítima]; perguntaram do que se tratava; divergiram; após, confessaram o crime de roubo do caminhão; posteriormente, outra equipe conseguiu abordar caminhão já em Campo Limpo Paulista, o qual confessou o crime e disse que havia mais duas pessoas em um veículo santana branco, que levaram as vítimas à capital do estado; não há divisória nas vias da rodovia; abordaram o celta após 1-1,5 km; os acusados não

resistiram à abordagem policial; foi o depoente que localizou a CNH no porta-luvas; quando chegaram ao local o veículo branco já havia saído com as vítimas. Diogo Henrique Francez e Sá disse que recebeu informação que uma equipe conseguiu abordar veículo com algumas pessoas e que caminhão havia evadido do local; conseguiram abordar caminhão dos Correios; no momento da abordagem, condutor desembarcou e confessou o delito; realizou vistoria no interior do caminhão, tendo sido encontrado aparelho bloqueador de sinal que impedia qualquer tipo de comunicação; encontrou crachá do motorista do caminhão; encontrou com as vítimas posteriormente na delegacia; não se recorda de ter encontrado aparelho celular. Débora da Cunha Pereira expôs que estava em patrulhamento com parceiro; receberam informação via rádio de que caminhão roubado estava na rodovia sentido Campo Limpo Paulista; encontraram caminhão, realizaram abordagem; condutor informou que realmente era produto de roubo; posteriormente disse que iria se encontrar com outras duas pessoas e que iriam em outro lugar; encontram bloqueador de sinal no interior do veículo; acusado relatou que vítimas foram colocadas em carro branco e levadas a outro lugar que desconhecia. Passa-se à análise da autoria delitiva.

José Eduardo Alves dos Santos negou os fatos; expôs que Rogério queria fazer uma festa de aniversário para o filho; comentou a ele que tinha um amigo (Paulo) que tinha sítio próximo a Campo Limpo Paulista e Jarinu; "com certeza ele aluga"; "quer dar uma passada lá?"; Rogério aceitou; no sábado de manhã rumaram ao local; parou para abastecer o carro na Rodovia Anhanguera; passou no caixa eletrônico do mercado Dia para sacar dinheiro; indo ao sítio, "de repente uma viatura encostou atrás"; "ficou um bom tempo atrás"; deram sinal para encostar; revistaram; perguntaram se tinha passagem; disse que sim (art. 180), desde 2004; perguntaram a Rogério também e "ficaram bravos"; sentaram os dois no chão e revistaram o carro; falaram que tinham mexido em carreta; negaram; levaram Rogério para dentro do mato, deram tiro para cima; quando voltaram com ele insistiram sobre a carreta, ao que negaram; levaram até a delegacia; "bem depois" chegou o delegado; deixaram em "jaulinha"; explicou ao delegado, que não quis saber de ouvir; não tinha nada no carro em que estavam; nunca tinha visto os policiais; sobre José Marcos, não o conhece; no mesmo horário do delito estava no mercado, a quase 50 km do local dos fatos; José Marcos disse que "foi dirigir uma carreta"; celta que conduzia pertence a Sandro. Rogério Ribeiro de Santana negou os fatos; disse que filho faria aniversário; queria alugar chácara; [José] Eduardo levou o carro ao lava-rápido do depoente, e expôs que conhecia um rapaz que tinha sítio e era "barateiro"; combinaram de ir no fim de semana; foram sentido sítio; duas paradas: no posto de gasolina e no supermercado Dia; tirou dinheiro no mercado Dia; um pouco mais para frente, foram abordados; "abordagem de rotina"; desceram do carro; agente perguntou se tinha passagem; disse que sim, ao que o agente perguntou "e a carreta do Sedex?"; negou; "fala onde tá a carreta ladrão"; apanhou; revistaram veículo, não acharam nada; chegaram outras viaturas depois; "já que ele não quer falar, vamo levar ele pro mato"; permaneceu apanhando; policial pegou uma arma e tentou colocar na mão do depoente; agente contou até três e deu um tiro para o alto; taparam a boca do depoente e foram até José Eduardo; após isso colocaram ambos no acostamento da rodovia; em momento nenhum tinha alguma coisa no veículo, apenas telefones e carteira de Eduardo; questionaram Eduardo sobre os cartões (que estavam em nome da esposa de Eduardo); quando chegaram à delegacia, escrivão perguntou aos policiais se haviam confessado; disse que sim, embora não tenham confessado; delegado chegou depois; sobre José Marcos, não o conhece; viu apenas na delegacia; já estava lá; disse que tinha sido pego dirigindo a carreta, que "cara" tinha pago ele para dirigir carreta.

A versão dos acusados é isolada no acervo probatório.

Com efeito, os policiais Germano Faria Júnior e Anselmo Wellington Bueno efetivaram a prisão em flagrante dos acusados, que estavam no veículo celta, logo após tê-los visualizado em conjunto com José Marcos, certo que em seu interior localizaram o documento de uma das vítimas (Ezequiel). Tal constatação, aliada à afirmação dos agentes de que visualizaram os três acusados nas proximidades do caminhão roubado, tendo José Eduardo e Rogério se dirigido ao celta após visualizarem a guarnição,

empreendendo fuga sentido Campo Limpo Paulista, constitui indício insofismável da autoria delitiva.

Consigna-se que não há nenhuma prova que desabone o depoimento dos policiais, todos convergentes à autoria delitiva. Em reforço: "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras [...]. (TJSP; Apelação Criminal 0042154-53.2018.8.26.0050; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022)" - grifou-se.

No mais, de se pontuar que o relato das vítimas é harmônico e coerente, assumindo especial relevância: "Revisão criminal. Roubo. Extorsão. Autoria. Prova. Depoimento da vítima. O depoimento da vítima reveste-se comumente de grande importância para a elucidação de investigações de crimes patrimoniais, notadamente quando nada de concreto desabona seu devido crédito. (TJSP; Revisão Criminal 0054749-74.2017.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 6º Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 31ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022).

Nesse sentido, ambas narraram que: a) foram fechadas por um veículo, que as mandou descer do caminhão; b) foram colocadas em um veículo com quatro portas, encapuzadas, e levadas para São Paulo; c) havia duas pessoas no veículo que levadas até São Paulo; d) estavam armados (embora Ezequiel apenas tenha sentido, e não visto).

Apesar de algumas divergências pontuais, como o fato de estarem/não estarem encapuzadas e a pretensa identificação como policiais civis, é certo que o temor causado foi suficiente à subtração do veículo.

Por fim, a dinâmica relatada pelas vítimas - especialmente Ezequiel - de que havia cinco assaltantes, dos quais três ficaram no local e dois as levaram para São Paulo, é idêntica à informada pelos quatro agentes, que as obtiveram das confissões informais, em respaldo à comprovação da consumação do delito.

Assim, a condenação é mandatória, nos exatos termos da denúncia.

Sobre a restrição da liberdade das vítimas, não há qualquer controvérsia, porquanto ambos retirados do caminhão roubado e colocados em um veículo - possivelmente um santana branco - com destino a São Paulo, onde permaneceram por cerca de uma hora até serem libertados.

No tocante ao emprego de arma de fogo, igualmente inquestionável. Ao relato específico de Cariolando - que viu a arma - e Ezequiel - que a sentiu - deve ser acrescido que "para a configuração da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato utilizado no crime, podendo ser comprovado o efetivo uso do instrumento por outros meios de prova, tal como a oral (no caso, declarações das vítimas) (TJSP; Apelação Criminal 1501820-26.2020.8.26.0536; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cubatão - 3ª Vara; Data do Julgamento: 26/07/2022; Data de Registro: 26/07/2022)".

Com relação ao concurso de agentes, igualmente incidente, pois a vítima Ezequiel declarou que havia cinco pessoas no veículo que o fechou; por sua vez, embora Cariolando não tenha informado o número de pessoas, também disse que o veículo utilizado para levá-los a São Paulo contava com duas pessoas; por fim, os agentes efetivaram a prisão em flagrante de três pessoas, a denotar a coautoria, nos exatos termos do art. 29 do CP.

Por fim, sobre a causa de aumento do art. 157, § 2º, III, do CP, descabida a inclusão. De acordo com a doutrina, por transporte de valores "tanto podem ser representados por dinheiro, como por qualquer outro efeito que se costuma transportar (n.b.: transportar, e não portar), como sejam: pedras preciosas, ouro em pó ou em barra, selos, estampilhas, títulos ao portador etc." (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal, v. VII, p. 59); no caso, não houve transporte de valores, mas de objetos dos Correios, os quais, a despeito do inequívoco conteúdo econômico, não se amoldam à hipótese, sob pena de analogia in malam partem, vedada no Direito Penal.

Além do roubo de caminhão, os acusados devem responder pelo roubo dos pertences da vítima Ezequiel, encontrados no celta preto, em concurso formal, na medida em que todos os elementos – à exceção de sua negativa – denotam que todos estavam em conjunto no momento da abordagem, com o encontro de parte dos pertences da vítima no interior do veículo em que estavam.

Sobre o art. 288 do CP, o dispositivo prevê que constitui crime a conduta de: "Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes". Em comentário ao delito, Nelson Hungria (HUNGRIA, Nélson. Comentários ao código penal, v. IX, p. 177) destacava que: "Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial" – grifou-se.

Neste norte, imprescindível a demonstração dos requisitos da estabilidade e permanência: "para a caracterização do delito de formação de quadrilha são necessários o concurso de pelo menos quatro pessoas, a finalidade dos agentes voltada ao cometimento de delitos, bem como exige-se a estabilidade e permanência da associação criminosa, o que não se verifica no caso vertente" (Resp 1054460/SP). Consequentemente, inviável sejam tais requisitos presumidos: "AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. LOCALIDADE DOMINADA POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE (STJ, AgRg no HC 471155/RJ) – grifou-se.

No caso, apesar de as provas dos autos indicarem que havia 5 (cinco) pessoas na empreitada, não há qualquer elemento que indique que estavam associadas em caráter estável, mas mero concurso eventual de agentes. Logo, com fundamento no art. 386, II e VII, impõe-se a absolvição do acusado.

Passa-se à dosimetria das penas.

Na primeira fase, em atenção ao art. 59 do CP, ambos os acusados possuem condenações pretéritas. Rogério foi condenado nos processos n. 0076902-97.2007.8.26.0050, 0077179-45.2009.8.26.0050, 0001057-58.2017.8.26.0616 – esta com trânsito em julgado posterior à data dos fatos em análise (fls. 1235/1239). José Eduardo foi condenado no processo n. 0002099-09.2017.8.26.0628 – esta com trânsito em julgado posterior à data dos fatos em análise (fls. 1240/1245), mas suficiente à elevação de pena-base em 1/6 em razão dos maus antecedentes.

Neste norte: "segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020).

Sobre a culpabilidade, em se tratando de roubo circunstanciado pela restrição da liberdade das vítimas, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, a circunstância do art. 157, § 2º, V, do CP será utilizada para exasperar a pena na primeira fase, acrescentando-a de 1/6, ante a maior reprovabilidade concreta da conduta.

Nesse sentido: "É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta" (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1990966/TO) – grifou-se.

As demais circunstâncias não excedem a gravidade inerente à abstração do tipo.

As consequências aos ofendidos estão abrangidas pela causa de aumento do § 2º, V, do CP, acima valorada. Sobre a personalidade e conduta social dos acusados, nada há nos autos que represente desabono, consignando que "a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente" (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019).

Desta forma, as penas-base são fixadas em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, a confissão, ainda que informal, uma vez que utilizada como argumento para a condenação, é compensada pela reincidência de Rogério (processo n. 29088-11.2015.8.26.0050), mantida sua pena no patamar prévio. Com relação a José Eduardo, é tecnicamente primário, impondo-se o decréscimo de 1/6 à pena, ajustada para 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Em reforço: "a confissão informal do Acusado de que venderia os entorpecentes, feita aos policiais no momento de sua prisão em flagrante, foi utilizada no acórdão atacado para se concluir pela autoria delitiva e ratificar a sentença condenatória. Assim, faz ele jus à atenuante da confissão, ainda que tenha retratado suas declarações em juízo" (AgRg no HC 687484/SP).

Na terceira fase, presentes as causas de aumento relacionadas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

O STJ, na súmula 443, assentou que "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Considerando que a circunstância do § 2º, V, do CP foi utilizada para exasperar a pena-base, de rigor o acréscimo de 1/3 pelo concurso de agentes e 2/3 pela utilização da arma de fogo, esta prevista em parágrafo específico do art. 157 (§ 2º-A, I).

Chancelando a possibilidade de soma dos acréscimos das circunstâncias do § 2º e § 2º-A: "[...] na derradeira etapa, penas dos roubos majoradas em 1/3 pela majorante do concurso de agentes e mais 2/3 pela causa de aumento do emprego de arma de fogo. Entendimento que não se revela ilegal [...]" (TJSP; Revisão Criminal 0043188-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022)".

Descabido o aumento sucessivo das causas de aumento, pois incidentes na mesma fase da dosimetria. Assim, impõe-se o acréscimo de 3/3, conforme já assentado em precedentes da Corte: "[...] Na derradeira etapa, em vez de aplicar os percentuais de aumento sucessivos pelo concurso de agentes e emprego da arma de fogo mais adequada a soma dos percentuais para a adoção de um único percentual nesta fase única, ou seja, 3/3 [...]" (TJSP; Apelação Criminal 1500225-39.2021.8.26.0315; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Conchas - 2ª Vara; Data do Julgamento: 22/07/2022; Data de Registro: 22/07/2022) - grifou-se.

Portanto, a pena de Rogério é fixada em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa. Aplicada a fração (1/6) relacionada ao concurso formal de delitos, tem-se pena definitiva de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa.

Com relação a José Eduardo, a pena é fixada em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa. Aplicada a fração (1/6) relacionada ao concurso formal de delitos, tem-se pena definitiva de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

O regime inicial é o fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), com fixação do valor

unitário do dia-multa no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP). Descabida a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de suspensão condicional, pois não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP.

Posto isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar JOSÉ EDUARDO ALVES DOS SANTOS e ROGÉRIO RIBEIRO DE SANTANA como incurso na conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, por duas vezes, em concurso formal próprio, às seguintes penas: a) Rogério Ribeiro de Santana: 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa; b) José Eduardo Alves dos Santos: 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa; absolva-los, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP da imputação pela prática do delito do art. 288 do CP.

O regime inicial para ambos os acusados é o fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), com fixação do valor unitário do dia-multa no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP). Mantidos os fundamentos da decisão das fls. 256/258, aos quais se acresce a presente condenação, de rigor a manutenção da custódia cautelar dos acusados, já considerado o período depurador (art. 387, § 2º, do CPP). Em caso de recurso, expeça-se guias de execução provisória das penas.

Comuniquem-se os ofendidos sobre a prolação da sentença (art. 201, § 2º, do CPP). Após o trânsito em julgado: a) expeçam-se guias de execução definitiva; b) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF/1988, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; c) oficie-se ao IIRGD; d) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima permitida ao defensor dativo, se o caso.

Custas pelos acusados nos termos dos arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela instrução processual (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-os para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP). Recolhida, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ.

Registro dispensado (art. 72, § 6º, das NSCGJ).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Campo Limpo Paulista, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA